

1512254-79.2021.8.26.0038

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/05/2022

... conforme previsto no art. 33, "caput", a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe de prova da venda da droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração do delito, na modalidade de "trazer consigo" entorpecente para fins de tráfico.

Acerca da caracterização do crime de tráfico pela execução de qualquer verbo do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Foro de Araras

Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras - SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1512254-79.2021.8.26.0038 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512254-79.2021.8.26.0038

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEITON FONSECA DO PRADO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

VISTOS.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face do acusado CLEITON FONSECA DO PRADO, já qualificado, visando apurar a prática dos delitos previstos no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Notificação, fls.114.

Recebida a denúncia, o réu foi citado (fls.116 e 148).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas. O réu foi interrogado.

As partes debateram.

O Ministério Público pediu a condenação. A Defesa requereu absolvição, regime aberto e substituição de pena.

É o relatório. Passo a fundamentar.

Preliminarmente, entendo não ser o caso de determinar instauração de incidente de dependência toxicológica. Isto porque, conforme entendimento majoritário no STJ (HC 258463/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma) a mera suspeita ou afirmação de que o acusado seja usuário de substâncias ilícitas não justifica a realização de exame em análise.

Vejamos: A simples alegação de ser o réu viciado em substâncias entorpecentes não obriga o magistrado a realizar o exame de dependência toxicológica, porquanto cabe ao juiz, no caso concreto, avaliar a conveniência e a oportunidade de sua realização (RHC 14.789/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 07.10.2003, DJ 10.11.2003 p. 198).

Assim sendo, deve-se avaliar se existem nos autos informações seguras de que o réu seria incapaz de entender o caráter ilícito de sua ação no momento em que foi praticada.

Nunca é demais lembrar que somente a dependência química enseja a isenção ou redução de pena, benefícios não aplicáveis aos meros usuários, ainda que completamente incapaz de entender o caráter ilícito da conduta - exceção feita às situações provenientes de caso fortuito ou força maior - aplicando-se a teoria adotada pela legislação vigente, no Código Penal e na Lei de Tóxicos, da "actio libera in causa".

No mérito, a condenação é de rigor.

A materialidade delitiva está estampada nos auto de exibição e apreensão, bem como pelo laudo de exame toxicológico juntado aos autos (fls.21 e 72/74).

A autoria restou igualmente comprovada.

De fato, os policiais militares foram claros ao relatar que, em patrulhamento de rotina em local afamado pela de tóxicos, avistaram o réu que fugiu ao notar a chegada dos agentes do Estado. Durante a fuga, o denunciado jogou sobre um telhado invólucro posteriormente apreendido, dentro do qual encontradas oito porções de maconha. Em revista pessoal, escondidas em sua cueca, lograram desvendar 39 porções de cocaína. Em seu bolso, apreenderam ainda mais 4 porções de crack e 70 reais. Indagado, o réu teria confessado informalmente aos policiais a prática de tráfico.

Lembre-se aqui os agentes públicos nada lograriam ao imputar falsamente crime gravíssimo a pessoa sabidamente inocente. Assim sendo, e também por não serem legalmente suspeitos ou impedidos, suas palavras gozam de força probatória em juízo.

Nesse sentido: "Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório" (STJ, Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, HC nº 115516/SP 03/02/2009).

O réu, por sua vez, interrogado em juízo, negou a autoria de tráfico, admitindo a posse das 8 porções de maconha e 4 "pedras" de crack. Afirma que dispensou referidas drogas num telhado e que eram destinadas ao seu uso pessoal. Nega a propriedade das porções de cocaína. Relata ter sido agredido e ameaçado pelos policiais

A negativa de autoria, como sói ocorrer, está isolada e não pode prevalecer. Prevalecem, pois, as palavras dos agentes estatais.

Acerca da preponderância dos testemunhos de agentes estatais sobre as palavras do acusado, transcrevo entendimento do E. TJSP:

"Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova". (TJSP, 9ª Câmara de Dir. Criminal, Apelação nº 0003339-74.2010.8.26.0144, da Comarca de Mogi-Mirim, de relatoria do Des. Souza Nery, em 21 de fevereiro de 2013).

A condenação é, destarte, de rigor.

A destinação da droga à traficância está evidenciada pelas circunstâncias do fato, eis que abordado em posse de drogas e dinheiro em local afamado pela venda espúria, bem como pela localização de mais drogas escondidas em sua roupa íntima.

No mais, a mera alegação de usuário, ou mesmo de vício, ainda que provada, não impede o reconhecimento da prática de tráfico.

Ao revés, é bem comum que usuários e adictos passem a comercializar drogas como meio de sustentar o próprio consumo. Nessa linha, já se pronunciou também o Tribunal Bandeirante:

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (RJ TJ 101/498).

"Lei de Tóxicos (nº 11.343/2006). Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável e ação surpreendida. Quantidade e acondicionamento da droga que revelam comércio. Palavras dos Policiais Militares coerentes e incriminatórias. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Desclassificação para uso impossibilitada. Circunstâncias que apontam para o tráfico. Regime acertado. Apelo improvido." (TJSP, ApCrim nº 990.08.070232-7 v.u. Rel. Luís Soares de Mello j. em 17.02.2009).

Irrelevante ao deslinde da causa a não demonstração de comercialização da droga no exato momento da prisão.

Isto porque, conforme previsto no art. 33, "caput", a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe de prova da venda da droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração do delito, na modalidade de "trazer consigo" entorpecente para fins de tráfico.

Acerca da caracterização do crime de tráfico pela execução de qualquer verbo do tipo, transcrevo entendimento jurisprudencial dominante, "ex vi":

"O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes" (TJRS, Ap. 697.020.717, Câm., j. 30-4-1997, rel. Des. Érico Barone Pires, RT 745/633)

Oportuno ainda lembrar que "para a configuração do crime previsto no artigo 12 da Lei n. 6.368/76, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo a substância entorpecente. Da mesma forma, é inexigível a tradição, para a consumação do delito" (Habeas Corpus n. 39.141-3 Rel. Des. Denser de Sá, RJ TJESP 97/512).

Na mesma linha de raciocínio já decidiu o STF que "a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de

comercialização" (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993 p. 11012).

Dosimetria da pena.

Primeira fase. Justificável o incremento da pena nesta fase exordial, em 1/6, em razão da quantidade de drogas bem como pela natureza altamente perniciosa do "crack".

"Não há nulidade na decisão que fixa a pena-base considerando fundamentação idônea, na qual estão compreendidas a natureza e a quantidade do entorpecente, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06" (STF HC nº 112798 / AC rel. Min. Carmen Lúcia j. 18/12/2012)

"(...)a penabase foi fixada 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, (...), tendo em vista a especial gravidade das circunstâncias fáticas do crime que envolvia o nefasto comércio ilegal de "crack", nos termos expendidos pelo art. 42, "caput", do Código Penal. (...) a potencialidade lesiva do crack e as consequências sociais do seu comércio ilegal acarretam clara violação à saúde e segurança pública, bens jurídicos tutelados pelo ordenamento jurídico" (TJSP, 4ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0000164- 38.2012.8.26.0262, da Comarca de Itapeva, de relatoria do Des. Salles de Abreu, em 16 de abril de 2013)

"DOSIMETRIA - AGENTE FLAGRADO COM CRACK - MANUTENÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO - Insuficiência: Além da maior gravidade da oferta de crack, substância com maior poder devastador, a quantidade de drogas aponta necessidade de maior reprovação da conduta e, por isso, insuficiente a manutenção da pena mínima. Recurso parcialmente provido, somente para redução das penas." (TJSP, 15ª Câm. Dir. Criminal, Apelação nº 0005278-47.2011.8.26.0664, de relatoria do Des. J. Martins, São Paulo, 04 de abril de 2013).

Segunda fase. O réu é reincidente (autos nº. 1116-34/2017 e 5000-71/2017 - fls.127/128), razão pela qual a reprimenda deve ser majorada em 1/4.

Terceira fase. Impossível a aplicação do redutor de pena do §4º, do art.33, em razão da condenação transitada em julgado acima mencionada.

Regime de cumprimento de pena. Deve ser o fechado por ser reincidente.

Progressão antecipada. Deixo de aplicar a regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), posto depender de requisitos não exclusivamente objetivos, tal qual o bom comportamento carcerário, inviável de aferição neste momento. Válido aqui consignar entendimento jurisprudencial majoritário: "No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei nº 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena". (TJSP, 16ª Câmara Criminal, Apelação n. 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel. Des. ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, julgado em 04.06.2013). " (...) não há como considerar o tempo preso, em aplicação da regra da detração, para fins de obter uma progressão de regime sem a aferição da completude de seus requisitos, nos planos objetivo e subjetivo, ex vi a previsão do artigo 112 da Lei de Execuções Penais". (TJSP, 16ª Câmara de Direito Criminal, HC n. 0152636-97.2013.8.26.0000, Rel. Des. OTÁVIO DE ALMEIDA MACHADO, julgado em, 22 de outubro de 2013).

Ante o exposto, JULGO parcialmente PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu CLEITON FONSECA DO PRADO, já qualificado, pela prática do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, ao cumprimento de pena privativa

de liberdade de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 728 dias-multa, no mínimo legal.

Custas processuais em 100 UFESPs.

Não poderá apelar em liberdade, pois condenado por crime gravíssimo. Justifica-se a custódia para garantia da ordem pública, eis que ostenta outra condenação já transitada em julgado. Recomende-se. Expeça-se guia provisória, em 05 dias.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos em favor da União (artigo 63, §1º, da Lei 11.343/2006). Determino, outrossim, a destruição dos bens e entorpecentes apreendidos no autos, independentemente de trânsito em julgado. Oficie-se. Expeça-se certidão de honorários ao patrono nomeado. Publique-se. Ciência ao MP.

Araras, 12 de abril de 2022.

(Liberada nos autos digitais em 01/05/2022)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA